

1519996-70.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1519996-70.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519996-70.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2225455/2021 - 24º D.P. PONTE RASA, 19715056 - 24º D.P. PONTE RASA, 3823/21/224 - 24º D.P. PONTE RASA, 2225455 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN KEVIN DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

JONATHAN KEVIN DA SILVA e LUIZ HENRIQUE JEREMIAS FERREIRA ALVES DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29 e artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal.

Eles teriam, no dia 19 de agosto de 2021, por volta de 01:00, na Travessa Thomaz Amirati, nº 10, Cangaíba, nesta Capital, em concurso de pessoas e unidade de desígnios, trazido consigo, para fins de traficância e consumo de terceiros, 87 (oitenta e sete) porções de cocaína, pesando 51,5 g (cinquenta e um gramas e cinco

decigramas), e 43 (quarenta e três) porções de tetrahidrocannabinol, conhecida como "maconha", pesando 15,1 g (quinze gramas e um decigrama), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R\$ 677,00 (seiscentos e setenta e sete reais) em espécie, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 24, laudo de constatação de fls. 57/60 e laudo químicotoxicológico definitivo de fls. 96/98.

Notificados os réus (fls. 173 e 174), ambos apresentaram a defesa prévia (fls. 182/185). Inviável a absolvição sumária, foi recebida a denúncia e designada a audiência de instrução e julgamento (fls. 196/200).

Encontram-se nos autos o auto de prisão em flagrante (fls. 5/6), o boletim de ocorrência (fls. 7/10), o auto de exibição e apreensão (fls. 24), o laudo de constatação preliminar (fls. 57/60) e o definitivo (fls. 96/98).

Ouvidas as partes, o Ministério Público requereu a condenação do crime nos termos da denúncia, regime semiaberto em razão da quantidade e qualidade da droga.

A defesa de Johnatan requereu a absolvição do acusado em razão da fragilidade do conjunto probatório ou, alternativamente, a aplicação da pena mínima.

A defesa de Luiz Henrique pleiteou a absolvição. Subsidiariamente: a) pena base: seja estabelecida no piso uma vez que favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59 do Código Penal; b) agravantes e atenuantes: seja aplicada a atenuante referente à idade do acusado (18 anos ao tempo dos fatos) e da confissão judicial; ademais, que seja afastada a agravante mencionada na denúncia uma vez que ausente nexo de causalidade entre a pandemia de Covid19 e o tráfico de drogas; c) causas de aumento e diminuição de pena: que a pena seja reduzida em 2/3 a teor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas; d) regime inicial de cumprimento de pena: seja estabelecido o aberto, o que se pede diante do montante de pena aplicado, da primariedade e do tempo de prisão provisória (desde 19.08.2021); e) substituição da pena: que a pena corporal seja substituída por pena restritiva de direito; f) recurso em liberdade: ausentes razões para a manutenção da prisão preventiva, que seja deferido ao acusado o direito de recorrer da r. Sentença em liberdade.

É o relatório.

Decido.

É procedente a ação penal porque, ao cabo da instrução criminal restou perfeitamente delineada a autoria e a materialidade do crime tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 conforme mais adiante se verá.

Com efeito, a materialidade delitiva foi aferida pelo teor do auto de exibição e apreensão (fls. 24) e dos laudos de constatação provisória (fls. 57/60), bem como pelo laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente (fls. 96/98), com resultados positivos para COCAÍNA e TETRAHIDROCANNABINOL (THC).

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes colhidos na fase inquisitiva. Veremos.

Felipe, policial militar, reconheceu os réus de uma ocorrência de tráfico de entorpecente. Estava com o Cabo Conquista. Tinha um disk-denúncia do local que era ponto de drogas. O local é uma rua do tipo viela. Jonathan já tentou fugir mas Luiz não esboçou reação. O parceiro pegou Jonathan e o a testemunha abordou Luiz. Os dois estavam com bolsa tipo pochete com maconha e cocaína. Eles estavam com drogas embaladas de forma parecida. Todo o entorpecente estava dentro da pochete de ambos. Também localizou dinheiro com os dois. Não se recorda se as notas era trocadas. Após breve diálogo, os dois confessaram o tráfico. Não os conhecia antes. Não chegou a vê-los vendendo a droga. Os fatos ocorreram na madrugada. O disk denúncia dava a descrição física dos traficantes que batiam com as dos réus. Reconhece Jonathan como sendo o de camisa branca e Luiz como sendo o de moleton bege. Jonathan declarou que estava recente no tráfico. Não questionou se o dinheiro apreendido era decorrente da venda da droga. Ele não aparentava ser morador de área livre. Recorda-se que Luiz portava mais dinheiro e entorpecente que Jonathan mas não sabe o valor. Não se recorda se o entorpecente retratado a fls. 37 foi o

entorpecente apreendido.

Cabo Conquista, também policial militar, declarou se recordar dos acusados. Através do disk denuncia, W2107152454, tomou ciência de que no local, dois indivíduos devidamente descritos estavam na prática ilícita há uma semana. Foram ao local com a viatura e logo avistou os indivíduos. Jonathan correu mas a testemunha conseguiu detê-lo. Com ele localizou uma pochete em sua cintura interior da qual localizou 10 trouxas de maconha e 10 de cocaína e 170,00 reais. O parceiro abordou Luiz que não esboçou reação. Com Luiz localizou uma pochete com 525,00 reais, 33 trouxinhas de maconha e 87 pinos de cocaína. Os dois admitiram a prática do crime para ajudar família. Não os conhecia antes dos fatos. Reconhece a fotografia de fls. 37 como sendo o entorpecente que estava com eles. Luiz está trajando o moleton bege e Jonathan está de blusa branca. Jonathan estava lucido e tranquilo e não aparentava ser noia. A fotografia de fl. 37 e a soma de tudo que foi apreendido. Não tem condições de identificar o que se encontrava com um ou com outro. Como se vê, o quadro probatório é sólido e não deixa dúvidas acerca da conduta delituosa do acusado. Os elementos de convicção colhidos na fase policial e em juízo revelam-se firmes e substanciais, apontando-o com segurança como agente criminoso, no caso vertente.

É sabido que no processo penal por tráfico normalmente a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, que efetivam a apreensão da droga. E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuisse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel.Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel.Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido ainda:

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência” (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96). Quanto a preliminar de nulidade da prova produzida, sob o fundamento de quebra da cadeia de custódia da prova, não comporta reconhecimento tal pedido.

A violação da cadeia de custódia - disciplinada pelos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal - não implica, de maneira obrigatória, a inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida. Nessas hipóteses, eventuais irregularidades devem ser observadas pelo juízo ao lado dos demais elementos produzidos na instrução criminal, a fim de decidir se a prova questionada ainda pode ser considerada confiável. Só após essa confrontação é que o magistrado, caso não encontre sustentação na prova cuja cadeia de custódia foi violada, pode retirá-la dos autos ou declará-la nula.

No caso em concreto, conforme se observa dos depoimentos prestados pelos policiais militares, mormente o relato trazido em juízo pelo policial Conquista, que foi claro e detalhoso em especificar as quantidades, tipos de drogas e valores em moeda que cada acusado trazia consigo são mais que suficientes e aptos a confrontar eventual irregularidade sobre prova questionada.

Superada a preliminar, seguem os depoimentos dos acusados.

Além de toda a prova oral colhida, idônea a fundamentar o decreto condenatório, temos a confissão dos acusados obtidas em juízo, vejamos.

Luiz Henrique declarou que tem 18 anos, é solteiro. Mora com os pais. Trabalha de

bico no Brás de, marreteiro e puxador. Reconhece os fatos. Estava com o entorpecente apreendido em seu poder. O dinheiro também estava com o interrogando. O dinheiro era da venda de droga. Estava com 400 ou 500 reais. O entorpecente era para ser vendido. Foi o primeiro dia de traficante. Estava sozinho quando foi preso e não conhece Johnatan.

Johnatan declarou que tem 21 anos de idade. Solteiro, mora com a mãe e a irmã. Foi a delegacia por conta de uma briga com a namorada. Trabalha como ajudante geral de uma transportadora em Guarulhos cujo nome não se recorda porque estava a pouco tempo. Reconhece que foi preso com o entorpecente. Estava com 8 ou 9 pinos de cocaína. Estava com 10 trouxinhas de maconha. Estava com 160,00 reais. Os policiais estão mentido. Foi preso três ruas de onde estava Luis foi preso. Não o conhece. O dinheiro é do bico que faz. Não verdade que foi abordado por volta das 1 da manhã e sim por volta das 23h40min estava em frente a uma pizzeria. Primeiro eles abordaram o acusado e ele reconheceu que estava com droga. Nisso passaram a transitar e acabaram encontrar outros policiais. Os policiais que foram ouvidos hoje foram os que prenderam o interrogando e não sabe quem prendeu o corréu. Daí porque, confrontados os elementos de prova, afigura-se de rigor a condenação.

Passo a dosar a pena:

1) JONATHAN KEVIN DA SILVA e LUIZ HENRIQUE JEREMIAS FERREIRA ALVES DA SILVA.

Fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Isto porque, a meu sentir, não há razões para que a pena base seja aumentada além do mínimo já que o tipos de entorpecentes apreendidos em posse deles bem como a quantidade, não desbordam do que ordinariamente ocorre.

Nada a justificar, a meu sentir, o aumento da básica por este fator. Portanto, quanto a este aspecto, discordo da posição trazida pelo Ministério Público.

Em segunda fase, afasto a agravante referente a calamidade publica eis que, a meu sentir, não houve prova alguma de que o circunstancia tenha agravado o crime ou facilitado sua pratica. Não há prova de nexo causal. De igual forma, a confissão e a menoridade relativa não serão utilizadas para o fim de se diminuir a pena aquém do mínimo legal.

Em terceira fase, pesem as ponderações trazidas pelo Ministério Público, entendo que é o caso de aplicação do trafico privilegiado, ou seja, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. O réu é primário e não possui maus antecedentes, fls. 128. Não se pode presumir, de outra banda, que ele se dedicava à atividade criminosa de forma habitual ou, ainda, que integrassem organização criminosa apenas porque ele e Luiz estivessem na posse de 66,6 gramas de entorpecentes, ainda que em sua forma variada. Só é viável o afastamento da benesse se a condição de reincidente ou portador de maus antecedentes, bem como de integrante de organização criminosa ou delinquente habitual, restarem devidamente comprovadas. Não basta que tenha sido preso em flagrante por tráfico para se atribuir ao réu a prática de atividades criminosas que impeçam a redução da pena. É necessário que dos autos, ou das circunstâncias da prisão, sobressaíam elementos indicativos de outras atividades ilícitas que não o próprio tráfico em si. E, seguido-se esse entendimento, no caso em apreço, a carga redutora a ser aplicada, considerando-se as circunstancias do caso concreto, é a máxima, ou seja, 2/3.

Assim sendo, diminuo a pena anteriormente aplicada em 2/3 (dois terços), com o que a reprimenda privativa de liberdade resulta em 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida.

2) LUIZ HENRIQUE JEREMIAS FERREIRA ALVES DA SILVA

Fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Isto porque, a meu sentir, não há razões para que a pena base seja aumentada além do mínimo já que o tipos de entorpecentes apreendidos em posse deles bem como a quantidade, não desbordam do que ordinariamente ocorre.

Nada a justificar, a meu sentir, o aumento da básica por este fator. Portanto, quanto a este aspecto, discordo da posição trazida pelo Ministério Público.

Em segunda fase, afasto a agravante referente a calamidade pública eis que, a meu sentir, não houve prova alguma de que o circunstancia tenha agravado o crime ou facilitado sua prática. Não há prova de nexo causal. De igual forma, a confissão e a menoridade relativa não serão utilizadas para o fim de se diminuir a pena aquém do mínimo legal.

Em terceira fase, pesem as ponderações trazidas pelo Ministério Público, entendo que é o caso de aplicação do tráfico privilegiado, ou seja, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. O réu é primário e não possui maus antecedentes, fls. 131. Não se pode presumir, de outra banda, que ele se dedicava à atividade criminosa de forma habitual ou, ainda, que integrassem organização criminosa apenas porque ele e Luiz estivessem na posse de 66,6 gramas de entorpecentes, ainda que em sua forma variada. Só é viável o afastamento da benesse se a condição de reincidente ou portador de maus antecedentes, bem como de integrante de organização criminosa ou delinquente habitual, restarem devidamente comprovadas. Não basta que tenha sido preso em flagrante por tráfico para se atribuir ao réu a prática de atividades criminosas que impeçam a redução da pena. É necessário que dos autos, ou das circunstâncias da prisão, sobressaiam elementos indicativos de outras atividades ilícitas que não o próprio tráfico em si. E, seguido-se esse entendimento, no caso em apreço, a carga redutora a ser aplicada, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, é a máxima, ou seja, 2/3. Assim sendo, diminuo a pena anteriormente aplicada em 2/3 (dois terços), com o que a reprimenda privativa de liberdade resulta em 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida.

Por fim, estabeleço o regime aberto para cumprimento da reprimenda. Isto porque, apesar de o art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90 determinar a fixação de regime inicial fechado para cumprimento do delito de tráfico de entorpecentes, por equipará-lo a hediondo, esta previsão não se aplica ao tráfico privilegiado. Como cediço, em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que o delito de tráfico de drogas, quando há o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não é equiparado a hediondo, nos termos da Lei nº 8.072/90, conforme se depreende do teor da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida” (Habeas Corpus nº 118.533/MS - Tribunal Pleno- Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 23.06.2016).

No mesmo sentido, os recentes Habeas Corpus nº 136.545, de relatoria do Min. Celso de Mello, j. 07.10.2016; nº 136.762, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.10.2016; e Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 937.651, de relatoria do Min. Roberto Barroso, j. 09.09.2016.

Consequentemente, concedo o apelo em liberdade.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO JONATHAN KEVIN DA SILVA e LUIZ HENRIQUE JEREMIAS FERREIRA ALVES DA SILVA, ambos qualificados nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, “caput” e § 4º da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhes a pena de 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no mínimo legal, e corrigidos desde a data do fato.

Outrossim, não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho meu entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão.

Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, até porque a conversão das penas privativas de liberdade não é automática, devendo o Magistrado analisar os preceitos estabelecidos do Código Penal.

No presente caso, temos que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos réus, que claramente praticavam o comércio de drogas é insuficiente para a prevenção e repressão do delito, sendo, portanto, sua concessão, vedada pelo art. 44, inciso III, e 77, II, ambos do Código Penal.

Os réus praticaram crime gravíssimo, sendo com eles apreendido drogas de alto potencial lesivo, drogas estas capazes de atingir a um sem-número de usuários e viciados. Assim, pelas circunstâncias concretas do crime, não há indicação de que tal substituição ou seja suficiente ou recomendável.

Cumram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, “d”, do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c.c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Decreto o perdimento dos valores apreendidos (fls. 24). Encaminhe-se ofício ao SENAD, comunicando acerca desta decisão e indicando a declaração de perdimento para os fins de sua destinação, ex vi do constante no art. 63, § 4º, da Lei n. 11.343/06; Transitada esta em julgado tornem concluso para a designação de data para audiência admonitória.

Expeçam-se Alvarás de Soltura Clausulados.

Isento de custas.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA